

1500169-26.2022.8.26.0588

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... de droga há cerca de 18 anos. Não pratica o tráfico de drogas e trabalha em serviços diversos, como carregador de cebola, batata, lavrador e barbeiro. Além da droga apreendida, não foi encontrado em seu poder nada relacionado ao tráfico, como balança e embalagem. Já foi processado criminalmente pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama

Vara Única

Praça São Sebastião, 126, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500169-26.2022.8.26.0588 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500169-26.2022.8.26.0588

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2133270/2022 -

DEL.POL.DIVINOLÂNDIA, 18631544 - DEL.POL.DIVINOLÂNDIA, 2133270 -

DEL.POL.DIVINOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FERNANDO HENRIQUE ANDRÉ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Fernando Henrique André, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, pelos fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 84/87).

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fl. 117), apresentando defesa escrita (fls. 131/132).

Após, a denúncia foi recebida (fls. 137/139) e o réu devidamente citado (fls. 151).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns, interrogando-se, em seguida, o réu.

Encerrada a instrução, em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência do pedido, condenando-se o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos ocorridos no dia 10/04/2022, desclassificando-se a conduta narrada no dia 25/05/2022 para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 200/210).

A defesa requereu, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugnou pela absolvição quanto ao fato ocorrido no dia 10/04/2022, com fulcro no art. 386, incisos I, II, V ou VII do CPP e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta denunciada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da lei supramencionada (fls. 214/224).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, o pedido formulado na denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01 do proc. 1500185-77), boletins de ocorrência (fls. 03/05, 71/72 e 31/33 do proc. 1500185-77.2022), autos de exibição e apreensão (fls. 8 e fl. 42 do proc. 1500185-77.2022), fotos das drogas apreendidas (fls. 11/15 e fls. 45/47 do proc. 1500185-77.2022), laudos periciais (fls. 17/19, 20/22 e fls. 104/125 e 126/128 do proc. 1500185-77.2022), relatórios de investigação (fls. 26 e 48/53 do proc. 1500185-77.2022), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 43 do proc. 1500185-77.2022), comprovantes de depósito (fls. 47 e fl. 100 do proc. 1500185-77.2022), link da mídia (fl. 108), auto de incineração de substância entorpecente (fls. 124/125), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é inconteste.

Na fase extrajudicial o réu disse que, num domingo à noite, caminhava nas proximidades do "Bar do Kiko Mariano", munido de pastéis e refrigerante, quando foi parado pelo conhecido "Nezão", que lhe entregou R\$ 15,00 referentes ao pagamento de um corte de cabelo que ele, interrogando, fez nele. Explicou que, além de lavrador, também corta cabelo de pessoas que solicitam seu serviço em domicílio, inclusive possui certificado desta profissão. Assim que recebeu o dinheiro de "Nezão", percebeu a chegada de uma viatura da Polícia Militar. Certo de que seria abordado, correu e deixou para trás aquilo que levava consigo, inclusive o dinheiro. Disse que era costumeiro ser abordado por policiais militares do município, inclusive era agredido fisicamente durante as abordagens. É usuário de "maconha", mas não portava nenhum tipo de droga quando fugiu da abordagem. Já foi processado criminalmente e preso pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mas cumpriu integralmente a pena (fl. 51). Disse que na manhã do dia 25/05/2022 policiais civis e militares estiveram em sua casa, cumprindo mandado de busca, oportunidade em que localizaram R\$ 17,00 em dinheiro, fruto do seu trabalho como carregador de cebolas, recebido no dia anterior. Também encontraram seu celular, que adquiriu de um amigo por R\$800,00 e uma porção de "maconha" que era para seu próprio consumo, visto que é usuário desse tipo de droga há cerca de 18 anos. Não pratica o tráfico de drogas e trabalha em serviços diversos, como carregador de cebola, batata, lavrador e barbeiro. Além da droga apreendida, não foi encontrado em seu poder nada relacionado ao tráfico, como balança e embalagem. Já foi processado criminalmente pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mas cumpriu integralmente a pena (fls. 05 dos autos 1500185-77.2022, em apenso).

Em juízo, negou a imputação que lhe é feita, alegando que a droga era destinada ao seu próprio consumo.

Na fase extrajudicial o policial militar Jonivaldo José Roque disse que na noite de 10/04/2022, efetuava patrulhamento com Edson Pereira Costa na área central de Divinolândia quando, em frente ao "Bar do Kiko Mariano", visualizaram o réu entregando algo para Anderson Sidnei Balbino, vulgo "Nezão". Como aquele é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e pesam contra ele denúncias de traficância, deram ordem de parada aos dois, oportunidade em que "Fernandinho" saiu correndo pela Rua Quinze de Novembro, sentido Praça Central. O PM Edson abordou Anderson, enquanto ele, interrogando, correu atrás do réu e o visualizou dispensando algo ao chão. Ao recolher os objetos dispensados, constatou tratar-se de duas porções de "maconha", embaladas em plástico filme e prontas para comércio, e duas notas de R\$ 2,00. "Nezão" trazia consigo um corote de pinga e uma porção de "maconha" embalada em plástico filme, idêntica às dispensadas pelo réu no momento da fuga. Indagado sobre o entorpecente, Anderson confirmou ter acabado de comprá-lo de Fernando, pagando R\$10,00 pela porção. Com autorização de Anderson, fizeram um vídeo dele, no qual ele confirma a compra do entorpecente. Foi registrado o B.O.P.M. sobre os fatos, sendo as drogas e dinheiro apreendidos, lacrados e encaminhados à delegacia da cidade (fls. 23), o que confirmou em juízo, acrescentando que o réu dispensou a droga e o dinheiro defronte ao "Bar do Paulinho", próximo ao local dos fatos. Anderson não foi apresentado imediatamente no plantão policial porque a necessidade de apresentação imediata dos envolvidos em ocorrências no período noturno é decisão do delegado plantonista. Anderson não estava embriagado e autorizou a gravação, porém não gravou tal momento, tampouco pegou sua autorização por escrito. Por se tratar de cidade pequena, as denúncias anônimas geralmente se dão pessoalmente e não são registradas. Além do dinheiro e da droga, o réu dispensou um pastel, o que não achou relevante para constar do registro da ocorrência. Por ocasião da busca e apreensão, a droga foi encontrada no quarto, não tendo sido encontrados outros apetrechos, como balança por exemplo.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Edson Pereira Costa, na fase extrajudicial (fls. 24), acrescentando que no dia 25/05/2022, por volta das 06h00, em apoio a policiais civis no cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão temporária expedido em desfavor de Fernando Henrique André, vulgo "Fernandinho", ele e o Sd. PM. "Roque" se deslocaram à Rua Eunice Machado Franchi, numeral 35-B, no centro de Divinolândia, ocasião em que foram atendidos por Lucimara, mãe de Fernando, a quem foi dada ciência de ambos os mandados. No interior do imóvel, Fernando, que se encontrava num dos quartos com o irmão, foi capturado e preso. Durante as buscas na casa, dentro da gaveta de uma cômoda, no interior de uma touca, foi encontrada uma porção da substância esverdeada, forte odor, similar a "maconha", embalada em plástico filme transparente e pronta para ser comercializada, semelhante às drogas dispensadas por Fernando, dias antes, quando ele fugiu da abordagem, após ser visto vendendo substância entorpecente para um usuário. Foi o próprio Fernando quem apontou a localização do entorpecente, alegando ser para seu consumo. Também foram localizados R\$ 17,00 em dinheiro no bolso de uma blusa do réu e seu telefone celular. É do conhecimento das Polícias Civil e Militar de Divinolândia que o réu já foi preso anteriormente pelo mesmo crime e que continua com a prática do tráfico de drogas na cidade. Fernando teve a voz de prisão em flagrante confirmada pela autoridade policial e foi submetido a exame cautelar no hospital Conderg (fls. 04 do proc. 1500185-77.2022), o que confirmou em juízo, acrescentando que não teve acesso ao conteúdo do celular apreendido na residência do réu. Anderson portava bebida alcoólica mas não estava embriagado e autorizou verbalmente a gravação do vídeo. Além do dinheiro e da droga, o réu dispensou um pastel. As denúncias anônimas geralmente são realizadas verbalmente, não possuindo registro. No Estado de São Paulo existe a Resolução 057, que permite o registro da ocorrência no dia posterior, por decisão do delegado plantonista.

O investigador de polícia Maxshuel Donizetti Leme, na fase extrajudicial, disse que no dia 25/05/2022, juntamente com PM. Edson, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão no endereço Rua Eunice Machado Franchi, nº 35-B, centro de Divinolândia, e mandado de prisão temporária expedido em desfavor de Fernando Henrique André. Na residência foi recebido pela mãe do réu e conseguiu capturar Fernando que estava num dos quartos do imóvel. Durante as buscas, dentro da gaveta de uma cômoda, no interior de uma touca, foi localizada uma porção da substância esverdeada, forte odor, semelhante a "maconha", embalada em plástico transparente e pronta para ser comercializada, que foi apontada pelo próprio réu, alegando ser para seu consumo. Também foram localizados R\$ 17,00 em dinheiro, no bolso de uma blusa do réu, além de seu telefone celular. Era do conhecimento das Polícias Civil e Militar de Divinolândia que o réu já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e que continuava com a prática do tráfico de drogas na cidade, sendo certo que havia se evadido da abordagem policial quando realizava a venda de "maconha" para um usuário. Naquela ocasião, durante a fuga, ele dispensou duas porções de "maconha" e R\$ 4,00 em dinheiro, que foram apreendidos pelos militares que participaram da ação, dentre eles o Cb. PM. Edson. O réu foi conduzido à Unidade Policial, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante que lhe fora dada. Após, o réu foi levado ao hospital local para exame médico cautelar (fls. 02/03 do proc. 1500185-77.2022). Também relatou que analisou o telefone celular do réu e constatou uma conversa do dia 24/05/2022, no aplicativo whatsapp, em que a interlocutora da linha (19) 99726-4410, apesar de não citar diretamente o entorpecente, deixou claro tratar-se de comercialização de drogas (fls. 48/53 do proc. 1500185-77.2022), o que confirmou em juízo, salientando que as denúncias anônimas geralmente são informais, inclusive feitas por presos. Na casa não foram encontrados objetos que caracterizassem a prática do tráfico, como balança, mas da análise do celular do réu verificou-se uma conversa realizada na noite anterior à busca em que a interlocutora pede a ele para lhe "servir" R\$50,00, o que não deixa dúvidas quanto a tratar-se do fornecimento de entorpecente.

Referidos depoimentos, apontando o réu como autor do crime pelo qual foi denunciado, harmonizam-se com os demais elementos de prova colhidos nos autos, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminá-lo.

Quanto ao depoimento de policiais, já se decidiu que "os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social" (RTJ 84/302).

Ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população. A lei não prevê a suspeição em razão da situação funcional.

Restou comprovado nos autos que no dia 10/04/2022 policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina na área central de Divinolândia, quando visualizaram Fernando Henrique André, conhecido como "Fernandinho", entregando algo para Anderson Sidnei Balbino, vulgo "Nezão".

Ao tentarem abordar os indivíduos, Fernando saiu correndo, dispensando ao chão duas porções de "maconha", que pesaram 10,31 gramas de massa líquida (fls. 17/19), e duas notas de R\$ 2,00 (fls. 47).

Com "Nezão" foi encontrada uma porção de "maconha", que pesou 6g de massa líquida (fls. 20/22), idêntica às dispensadas pelo réu durante a fuga.

Indagado, Anderson disse aos policiais que adquiriu a droga "do menino lá, o Fernando", pelo valor de R\$ 10,00 a porção e, na delegacia, disse que "apenas estava pagando o réu por um 'baseadinho' que tinha pagado com ele".

Tais evidências são suficientes para caracterização do tráfico de drogas, não deixando margem de dúvida quanto ao propósito mercantil do réu.

Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão na residência do réu e de prisão temporária deste, no dia 25/05/2022, foi localizada uma porção de "maconha", pesando 8,6 g de massa líquida (fls. 126/128 do proc. 1500185-77.2022), a quantia de R\$17,00 (dezesete reais) em dinheiro (fls. 100 do proc. 1500185-77.2022) e o telefone celular do réu.

Da análise do aparelho, contatou-se uma conversa via aplicativo whatsapp em que a interlocutora questiona Fernando "Custa me servir", e ele responde "Vc tem dinheiro". Ao responder que sim, Fernando continua "Vc quer quando", e a interlocutora responde "50".

Somem-se a isso, as denúncias anônimas recebidas pela polícia, informando da prática do tráfico de drogas pelo réu.

As circunstâncias, a quantidade de drogas apreendidas e a forma como estavam embaladas, somadas às denúncias de traficância recebidas pela polícia, não deixam dúvidas em relação à autoria, demonstrando que eram destinadas ao comércio ilícito.

Além disso, o réu possui condenação anterior pelo mesmo crime (proc. nº 672-44.2010.8.26.0588), o que reforça a certeza da autoria.

Importante ressaltar, porém, que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo, de forma que as condutas atribuídas ao réu configuram crime único.

Nesse sentido:

Apelação - Preliminar de nulidade - Oitiva de testemunha sem a presença do réu - Absoluta ausência de prejuízo - Acusado que foi representado por defensor nomeado - Preliminar rejeitada - Mérito - Tráfico de drogas, Receptação e Corrupção de menores - Acusado recebia objetos furtados pelos adolescentes, como forma de pagamento pela droga que lhes entregava - Comprovação da ciência da origem ilícita dos bens - Consistentes depoimentos dos menores envolvidos - Condenações pelos crimes de tráfico e de receptação, por duas vezes, mantidas - Afastado o concurso material entre os dois crimes de tráfico - Crime permanente que se protraí no tempo - Reconhecido crime único - Delito de corrupção de menores - Acusação que não especificou qual crime o réu teria praticado com os adolescentes - Sentença omissa a este respeito - Absolvição de rigor, neste aspecto - Penas ajustadas, após o afastamento do concurso material entre os crimes de tráfico, e a absolvição pela corrupção de menores - Regime prisional fechado mantido - Rejeitada a preliminar, dou parcial provimento ao recurso de apelação. TJSP - APL 0003931-98.2014.8.26.0073, Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Publicação: 16/08/2017, Julgamento: 10 de Agosto de 2017, Relator: César Augusto Andradede Castro. (destaquei)

Descabido, portanto, o pedido de revogação da prisão preventiva e de desclassificação do crime denunciado para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois restou comprovado que em ambas as oportunidades o réu praticou o delito previsto no art. 33 da mesma lei, tendo, no dia 10/04/2022, praticado a conduta "vender" e no dia 25/05/2022 "ter em depósito/guardar".

O depoimento da testemunha arrolada pela defesa em nada altera o contexto probatório.

Ouvido apenas na fase extrajudicial, Anderson, conhecido como "Nezão", disse que é usuário de drogas e estava apenas pagando "Fernandinho" por um "baseadinho" que

pegou com ele na semana anterior, pelo valor de R\$10,00 e que já o consumiu (fls. 25).

Destarte, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a condenação nos termos da denúncia, com a ressalva a respeito de se tratar de crime único.

Ressalto que é o caso de se determinar a perda, em favor do Funad, da importância em dinheiro apreendida nos autos (fls. 47 e fls. 100 do proc. 1500185-77.2022), pois não há dúvidas de que é produto de tráfico, e a perda, em favor da União, do aparelho celular do réu (fl. 100 do proc. 1500185-77.2022), pois não há dúvidas de que era utilizado para a prática da mercancia ilícita.

Antes de passar ao cálculo da pena, consigo que deve ser considerada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, pelo fato de o crime ter sido cometido durante a pandemia do Covid-19.

Passo, então, a dosar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do CP c.c. os artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006:

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem consideradas. Todavia, reconheço as agravantes da reincidência (proc. nº 672-44.2010, fls. 98 e 104) e a prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/3 (um terço), totalizando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão das precárias condições financeiras do réu, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é reincidente e as circunstâncias demonstram que se dedica à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Em razão da reincidência verificada, fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, observando-se o art. 387, §2º, do CPP.

Trata-se de réu que permaneceu preso durante todo o processo. Logo, deverá permanecer recolhido na prisão para apelar. Se já havia motivos para a custódia cautelar durante o trâmite processual, estes se mostram ainda mais presentes na medida em que ocorre a condenação. Ademais, trata-se de crime grave, tornando necessária a custódia para manutenção da ordem pública. Assim, indefiro o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia e condeno Fernando Henrique André, RG nº 48.714.408-9/SSP-SP, filho de Benedito Fernandes André e de Lucimara Alves Machado, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Indefiro o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra, servindo a presente, por cópia, como ofício de recomendação.

Após, extraia-se Guia de Execução, encaminhando-se ao DEECRIM competente.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada, se for o caso, a gratuidade processual.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do crime, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

Decreto o perdimento, em favor do Funad, da importância em dinheiro apreendida nos autos (fls. 47 e fls. 100 do proc. 1500185-77.2022), e a perda, em favor da União, do aparelho celular apreendido (fls. 42 do proc. 1500185-77.2022), nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o necessário.

Desde já, não havendo interesse pelo aparelho celular, fica autorizada sua destruição, observando-se o descarte da bateria.

Proceda-se na forma do art. 50, §3º, da Lei n.º 11.343/06, se necessário. Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA